

1500730-09.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico, pararam a viatura a uns 15 metros, fizeram campana de dez minutos e viram os réus, os quais se alternaram, servindo dois usuários. Os réus abriam uma caixa de luz, pegavam algo e entregavam. Abordaram os réus, os quais confessaram o tráfico. Foram até a caixa de luz e acharam porções de drogas e dinheiro trocado. Não conhecia os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500730-09.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500730-09.2022.8.26.0537 Controle n.º 580/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO MENDES DE JESUS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RAMOM LIMA CAMILO e CARLOS EDUARDO MENDES DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 13 de abril de 2022, por volta das 12:15 horas, na esquina das Ruas Raul Seixas e Clementina de Jesus, Bairro Jardim Casa Grande, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, adquiriram, guardavam e tinham em depósito, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas na audiência de custódia (fls. 69/72).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 117/118), sendo a denúncia recebida em 20.06.22 (fls. 143/144). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos

especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência do acusado Carlos (roubo e furto), fixação de regime fechado e perda do dinheiro apreendido. Em relação ao réu Ramom, diante da confissão, primariedade e por ser menor de 21 anos, requereu a redução do art. 33, §4.º e a fixação de regime aberto.

A Defensora Pública requereu a absolvição dos réus por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime do art. 28 quanto ao réu Carlos. Em caso de eventual condenação quanto ao réu Carlos requereu que seja fixada a pena no mínimo legal, aumento pela agravante da reincidência no mínimo e fixação de regime diverso do fechado e em relação ao réu Ramom, que sejam consideradas primariedade e menoridade, aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, os réus permaneceram calados (fls. 06/07).

O réu Carlos, em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que estava no local para comprar drogas, pegou a primeira, saiu e foi abordado. Foi para a loja de roupa beber água e foi abordado quando saiu da mesma. Trabalha como pintor, com reciclagem, tem curso de TI, estuda, sendo que não precisa atuar no tráfico. Tem condenação por roubo e já cumpriu a pena. Conhece o policial Cleber de vista por abordar pessoas na região. Foi comprar maconha e "crack". Mandaram aguardar, porque não tinha "crack" e iam abastecer. Então, foi até a loja de roupa e quando voltou já tinham abordado o corréu, sendo detido. Informou que quem estava vendendo era outro rapaz.

Ramom, em juízo, confessou que estava trabalhando no tráfico, porque precisava pagar o aluguel e sua esposa estava grávida. Trabalhava com produção, mas foi mandado embora e estava desempregado. O corréu é apenas usuário e estava chegando quando foi abordado, não tendo entregue drogas para aquele. Estava trabalhando desde as 8:00 hs e foi abordado por volta das 11 hs. Tem 21 anos e quando menor ficou de L.A por tráfico.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/05), disseram que o local é conhecido ponto de venda de drogas, que diligenciavam em uma viatura descaracterizada e realizaram breve campanha, quando observaram os réus em atitude suspeita. Relataram que os réus estavam na via pública, se deslocavam até um "quadro de luz" situado na Rua Raul Seixas, apanhavam um pequeno objeto do local e o entregavam a pessoas desconhecidas que se dirigiam a eles. Narraram que abordaram os réus e não encontraram nada de ilícito em poder deles, porém, ao verificarem o "quadro de luz", localizaram neste uma bolsa preta contendo 15 porções de maconha, 18 invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 55,00. Afirmaram que os réus confessaram que estavam traficando drogas no local. Informaram que não abordaram usuários, porque não foram identificados.

Cléber (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, pararam a viatura a uns 15 metros, fizeram campanha de dez minutos e viram os réus, os quais se alternaram, servindo dois usuários. Os réus abriam uma caixa de luz, pegavam algo e entregavam. Abordaram os réus, os quais confessaram o tráfico. Foram até a caixa de luz e acharam porções de drogas e dinheiro trocado. Não conhecia os réus.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Marcus Vinicius. Esclareceu que os réus estavam sentados em atitude suspeita. Viram os réus recebendo dois usuários e se alternaram para servi-los.. Disse que pegavam algo, atravessavam a rua, pegavam na caixa de luz e entregavam. Não conhecia os réus.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por

desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 18 invólucros de cocaína e 15 porções de maconha) e diversidade (cocaína e maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuários e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, e que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, bem como a confissão judicial do réu Ramom, a confissão informal dos réus, os depoimentos dos policiais, que presenciaram atos de mercancia, demonstram o tráfico, pois não teriam como adquirir essa quantidade se não fossem traficantes.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

O réu Ramom confessou e inocentou o corréu, dizendo que este era usuário e quando chegava no local foi abordado, mas que não entregou drogas para este. Porém, o corréu Carlos apresentou versão totalmente diversa, ou seja, que foi comprar maconha e "crack" e como não tinha, porque iam abastecer, saiu e quando retornou para pegar foi abordado. Isso demonstra que a tentativa de inocentar o corréu não pode ser acolhida, mesmo porque apresentam versões diversas e isso é desmentido pelos policiais que de forma uníssona nas duas fases informaram que houve confissão informal dos dois acusados e que viram ambos servindo usuários.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art.

28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 18 invólucros de cocaína e 15 porções de maconha), demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação dos réus, posto que a materialidade está demonstrada pelo laudo de constatação (fls. 14/16) e laudo definitivo (fls. 155/157).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados, que segundo consta dos autos, Carlos possui antecedentes (fls. 49/50 - proc. 4311-85.2017 - pena julgada extinta pela concessão de indulto em 28.03.17 - fls. 57) e é reincidente (fls. 50/51 - proc. 15316-70.2014 - pena julgada extinta em 29.11.21 - fls. 190) e Ramom é primário (fls. 62).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

"Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência do acusado Carlos será considerada como circunstância agravante.

Inobstante o réu Ramom tenha respondido por atos infracionais (fls. 61, 172 e 186), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 62 é primário e não ostenta antecedentes criminais (STJ, 5ª Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que o acusado Carlos possui antecedentes criminais, fixo a pena-base

em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100). Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes (fls. 49/50 – proc. 4311-85.2017 – pena julgada extinta pela concessão de indulto em 28.03.17 – fls. 57) e é reincidente por roubo (fls. 50/51 – proc. 15316-70.2014 – pena julgada extinta em 29.11.21 – fls. 190), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida, que reitera na prática de crimes e sequer demonstrou possuir ocupação lícita. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, o acusado Carlos não preenche o lapso temporal para tanto (preso em 13.04.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 12.08.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos antecedentes e da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Quanto ao acusado Ramom, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, §§ 2.º, "c" e 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO CARLOS EDUARDO MENDES DE JESUS à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA e RAMOM LIMA CAMILO à pena de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE

NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se acharem incursos no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu Carlos foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Quando ao acusado Ramom, considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, sobrevivendo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu Ramom.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03) por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 12 e 154) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto ao estojo de cor azul, sem marca aparente, apreendido (fls. 12) e já periciado (fls. 158/159), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 73), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 29 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA